

共犯の要素従属性に関して、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの()内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑥までの()内にはそれぞれ異なる語句が入る。

【会 話】

学生A. ①ことから、共犯を処罰するためには、正犯が②を備える必要があると考えます。

学生B. Aさんの見解によれば、甲が乙に指示して構成要件に該当する行為を実行させたが、③において、甲に責任を問うことができなくなり、不当ではありませんか。

学生A. その場合、甲に④を幅広く認めることで妥当な結論を得られます。

学生B. でも、乙が刑事未成年者ながら是非弁別能力があり、その意思が抑圧されていない場合にまで④を認めることは無理がありますね。他方で、適法な行為を援助する行為を処罰の対象とするのは妥当ではありません。私は、⑤べきと考えるので、共犯を処罰するためには、正犯が⑥を備えることが必要であり、それで足りることになります。

【語句群】

- a. 違法は連带的に作用するが、責任は個別的に作用する
- b. 教唆犯については刑法第61条が「犯罪」という文言を使っている
- c. 違法性阻却事由については、行為者ごとの違法の相対性も認められる
- d. 構成要件該当性 e. 構成要件該当性及び違法性
- f. 構成要件該当性、違法性及び有責性
- g. 乙の行為に違法性阻却事由が認められる事案
- h. 乙の行為に責任阻却事由が認められる事案
- i. 間接正犯 j. 幫助犯

1. ①a ③g ⑤c
2. ①b ③h ⑤c
3. ①c ④i ⑤a
4. ②d ④j ⑥f
5. ②f ④i ⑥e

No146	共犯の要素従属性	正答率
共通R5-16	正解	58%
	5	

() には順に、「① = b、② = f、③ = h、④ = i、⑤ = a、⑥ = e」と入り、したがって、正解は肢5となる。

①、②、③、④について

教唆犯(61条)や幫助犯(62条)に関し、正犯への従属性の要否をめぐる見解の対立があるが、教唆犯や幫助犯が成立するためには、正犯の行為が現に実行されたことが必要であるとして、実行従属性が一般には承認されている。この実行従属性が承認されるとしても、正犯者に犯罪にどの程度従属するのか別途問題にされており、これが要素従属性の問題である。この点、教唆犯について61条が、「犯罪」を実行させた規定していることから、正犯行為が構成要件に該当し違法であるだけでなく、有責な行為でなければならない、すなわち犯罪としての要件を全て具備しなければならないとする極端従属性説という見解がある。この見解は、正犯に責任が認められない場合、教唆犯や幫助犯は成立せず、従犯に責任を問うことができなくなり、不当な結論となるという批判があり、これに対しては間接正犯を広く認めることで対応するという反論をすることとなる。学生Aの第一発言と第二発言、学生Bの第一発言はこのことに言及していると考えられる。

これに対して、学生Bの第二発言は、甲が乙に指示して構成要件に該当する行為を実行させた場合に、乙が刑事未成年者ながら是非弁別能力があり、その意思が抑圧されていない場合を問題としている。これは、乙が刑事未成年者である場合には、責任は否定される一方、是非弁別能力があり、その意思が抑圧されていない場合には、甲が乙を道具として利用しているとは評価しづらく、間接正犯の成立を認めることは困難であるからである。したがって、①には「b. 教唆犯については刑法第61条が『犯罪』という文言を使っている」が入り、②には「f. 構成要件該当性、違法性及び有責性」が入り、③には「h. 乙の行為に責任阻却事由が認められる事案」が入り、④には「i. 間接正犯」が入る。

⑤、⑥について

さらに、学生Bは第二発言において、適法な行為を援助する行為を処罰の対象とするのは妥当ではないという価値判断を示している。これは、その前段で、正犯に責任まで具備することを要求するのは不当であるとした上で、違法性は連帯することが望ましいとしていることから、学生Bは、共犯の要素従属性について、正犯の行為が構成要件に該当し、かつ違法であることが必要であるとする制限従属性説を支持していることがわかる。したがって、⑤には「a. 違法は連带的に作用するが、責任は個別的に作用する」が入り、⑥には「e. 構成要件該当性及び違法性」が入る。